

1500549-86.2021.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500549-86.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-86.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/001062

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FAUSTINO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 85/86, no dia 22 de julho de 2021, por volta das 01h40min, na Rua Olaria, via pública, nesta cidade e comarca de São Sebastião, JEFFERSON FAUSTINO DA SILVA, qualificado as fls. 04, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 281 (duzentos e oitenta e um) papérolas com Cannabis sativa L., substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 1063,9g, além de possuir a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 106/111.

Em razão destes fatos, o réu JEFFERSON FAUSTINO DA SILVA, qualificado as fls. 04, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante delito, com fundamento nos artigos 282, 310, II e 312, do Código de Processo Penal, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 66/67).

Recebida a denúncia (fls. 92), o réu foi citado (fls. 123) e apresentou resposta à acusação (fls. 126/128). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 130/132). Designada audiência, em instrução foi procedido ao interrogatório do réu (fls. 171) e colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 172/173). A defesa solicitou prazo para que fossem arroladas testemunhas que presenciaram os fatos (fls. 169/170). Com o decurso do prazo, a defesa manifestou-se no sentido de que não conseguiu arrolar novas testemunhas para serem ouvidas (fls. 177/181). Em memoriais de alegações finais de fls. 159/166, o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na peça acusatória.

A Defesa do réu, por sua vez, aduzindo que não devidamente provado os fatos narrados e exordial acusatória, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da lei de drogas, em seu grau máximo. Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que o réu possa recorrer em liberdade. Por fim, pugnou que seja aplicado ao réu o instituto da detração penal e, ainda, que o réu seja isento do pagamento de eventual multa a ser aplicada (fls. 202/215).

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade se evidenciou pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de folhas 06/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 11, imagens de fls. 24, 27 e 32, relatório final de fls. 69/70, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 106/111, que revelou resultado positivo para a presença de "maconha", bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu. Vejamos:

A testemunha policial Fábio Rodrigo Biazzi Fonseca, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que estava em patrulhamento pelo bairro Olaria nesta urbe. Ao passarem por um escadão - um ponto conhecido utilizado para mercancia de entorpecentes - observaram a presença de dois indivíduos suspeitos e resolveram realizar a abordagem, momento em que os indivíduos empreenderam fuga. O depoente relatou que um deles (ora acusado) trazia consigo uma mochila azul. Tal indivíduo foi alcançado, porém conseguiu se desvencilhar e novamente empreendeu fuga, deixando para trás a referida mochila que continha em seu interior 267 porções de "maconha". Durante a fuga, o acusado Jefferson teria transposto um muro com cerca de três metros de altura, mas foi cercado por outros policiais no apoio. O réu foi detido e em seu poder foram encontrados 14 porções de "maconha" e R\$ 60,00 em espécie. Salientou que o outro indivíduo não foi detido. Jefferson foi encaminhado até o UPA para atendimento médico, pois apresentava escoriações diversas devido à queda que sofreu durante a transposição do muro, que era alto. Não conhecia o acusado de outras abordagens. À Defensora respondeu: O outro indivíduo que estava no local da abordagem conseguiu fugir; não havia mais ninguém no local para ser arrolada como testemunha; não sabe informar a distância entre o local da abordagem e o local em que o acusado foi contido; foi necessário o uso de força para deter o acusado; a maioria das lesões que ele apresentou se deu em razão de sua queda, porém alguns arranhões podem ter surgido durante o algemamento, já que ele resistiu à prisão.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar João Carlos Duque da Silva, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acrescentou que não conhecia o acusado de outras abordagens.

Na fase inquisitiva, o réu JEFFERSON FAUSTINO DA SILVA preferiu manter-se calado.

Não relatou nada acerca das supostas agressões que sofreu por parte dos policiais militares que realizaram a sua prisão.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu JEFFERSON negou a prática delitativa, cuja autoria lhe é atribuída. Narrou que estava na rua, em frente à casa de sua mãe, em um bar, bebendo. O bar fechou e permaneceu mais um tempo na rua. Nesse momento, os policiais o abordaram dizendo que o interrogando estava em um ponto de droga no morro e que tinha "dado fuga". Disse que os policiais lhe agrediram até ele desmaiar, vindo a acordar somente no hospital. Na delegacia, atribuíram-lhe a posse de uma bolsa contendo droga e começaram novamente a lhe agredir, até assinar o "papel". Não conhecia os policiais que o prenderam, bem como não soube informar o motivo pelo qual os policiais estão lhe incriminando. Ao Ministério Público respondeu: Disse que no local da abordagem haviam duas mulheres, que conhecem o interrogando desde criança, são suas vizinhas e presenciaram os fatos. Afirmou que pediu para tais mulheres chamarem a genitora dele, porém, como a genitora dele estava dormindo, "ela não foi na hora". Disse que já foi preso anteriormente por crime idêntico, mas foi "liberado". Não conhece os policiais que o prenderam. Afirmou que é usuário de drogas e que não tinha dinheiro no momento da abordagem. À Defensora respondeu: os policiais que o agrediram são os mesmos que prestaram depoimento nesta audiência; as vizinhas que se referiu acima, foram as mesmas que registraram o áudio do momento em que o interrogando foi agredido; na Prefeitura, exercia função de Ajudante Geral.

Pois bem.

As declarações do réu não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. O réu negou todos os fatos que constam da denúncia. Disse que estava em frente à residência dele, quando foi abordado por policiais que sequer conhecia, que imputaram a ele - gratuitamente - o gravíssimo delito de tráfico de droga. Não trazia consigo nada de ilícito. Negou que estivesse próximo ao "escadão", bem como que tenha empreendido fuga. Disse que foi agredido até desmaiar e só acordou nas dependências do hospital. Afirmou que perante a autoridade policial foi novamente agredido e obrigado a "assinar o papel". Não soube informar o motivo pelo qual os policiais estão lhe incriminando injustamente. Duas vizinhas dele presenciaram o ocorrido, mas não foram arroladas, pois temiam represálias por parte dos policiais. Pediu para tais mulheres chamarem a genitora dele, porém, como a genitora dele estava dormindo, ela "não foi na hora". Já foi processo por tráfico de drogas. A versão dada por ele é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Perante a autoridade policial preferiu se calar acerca dos fatos (fl. 04), mas ainda assim afirmou que foi "agredido até assumir a propriedade das drogas e assinar o papel". Não relatou nada acerca das supostas agressões que sofreu por parte dos policiais militares que realizaram a sua prisão. Tampouco, utilizou-se dos meios disponíveis para denunciar os policiais, ainda que de forma anônima. Além disso, o réu também poderia ter registrado um boletim de ocorrência delatando o ilícito, supostamente cometido pelos mesmos policiais, mas não o fez. Nenhuma comunicação à Corregedoria da Polícia Civil foi apresentada pela Defensoria Pública relatando os supostos abusos e as supostas agressões. O réu admitiu que esteve em um bar pouco antes da abordagem policial, mas sequer arrolou o dono do bar para confirmar sua versão. Segundo o réu, tal bar fica em frente à sua residência, onde sua genitora dormia no momento do fato, mas a própria genitora do réu não compareceu na delegacia de polícia, tampouco em juízo.

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou

concessão de benefícios legais". GN

Ademais, o acusado também não comprovou atividade lícita, apesar de afirmar que estava trabalhando. As declarações produzidas nos autos não têm o condão de alterar a situação fática, tampouco desacreditar o depoimento dos agente da lei. Por outro lado, os policiais militares narraram os fatos em conformidade com as provas dos autos. Os policiais militares forneceram relatos uníssonos e claros, referindo que estavam em patrulhamento em local conhecido pela mercancia de entorpecentes e avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Estes indivíduos empreenderam fuga ao avistarem os policiais. Após breve perseguição, os policiais conseguiram deter o acusado. Na mochila que trazia consigo localizaram 267 porções de "maconha". Em um dos bolsos dele foram encontrados outras 14 porções de "maconha" e a quantia de R\$ 60,00. Ambos os policiais não conheciam o acusado de outras abordagens.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminoso do acusado diante das provas produzidas.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSPAp.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU

04.06.1993, p. 11012).

Além disso, a quantidade das drogas apreendidas (281 papelotes contendo Cannabis sativa L., substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 1063,9 gramas), a forma de acondicionamento, individualizadas e prontas para comercialização, a importância apreendida em notas diversas, as contradições e a inércia do réu no sentido de provar suas alegações (onus probandi - CPP, artigo 156, caput), evidenciam que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros, não havendo falar-se em insuficiência probatória. Saliente-se que o réu está sendo processado por crime da mesma espécie, nos autos do processo nº 1500277-63.2019.8.26.0587 (fls. 87).

Incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado revela que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do réu. Também não é o caso de aplicação do artigo 45, ou mesmo artigo 46, ambos da Lei 11.343/06, visto que não houve comprovação nos autos a respeito da dependência química do acusado, providência que não foi requerida por qualquer das partes. A simples declaração de que é usuário de drogas não tem o condão de comprovar fato que demandaria perícia médica.

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa. Diante de todo o exposto, resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo em fls. 90/92 que o réu não ostenta maus antecedentes. Entendo não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade de entorpecente apreendido, na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há nenhuma atenuante ou agravante genérica.

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Dessa forma, diminuo a pena na fração de 2/3, tendo em vista pequena quantidade e a natureza das drogas apreendidas, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ainda que o acusado esteja sendo processado por crime da mesma espécie, nos autos do processo nº 1500277-63.2019.8.26.0587 (fls. 87), o processo citado não pode ser valorado para fins de reincidência ou maus antecedentes, tendo em vista que ainda se encontra em andamento, tampouco o órgão acusador demonstrou cabalmente que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial aberto (art. 33, §2º e §3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência,

CONDENO o acusado JEFFERSON FAUSTINO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime prisional inicial aberto, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando o quantum de pena e regime aplicados, bem como a ausência de fundamentos para a decretação de sua custódia cautelar. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro com ele apreendido, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Quanto à mochila apreendida, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto ao dinheiro, ao objeto e às drogas.

Condene o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA